



תיק מס' 90/14

המפקח על רישום מקרקעין בעכו
בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין: 1. אלבז שמעון יהודה

2. ליטבין ויאצ'סלב

3. קוזנצוב מיכאל

4. זיו חנה

5. אוחיון רמי

6. גולדשטיין רומן

7. חסין עופר

מרחוב חיים 22, ק. ביאליק

התובעים

נגד

פניני יפעת

רחוב חיים 22, ק. ביאליק

באמצעות אביה יוסף פניני

הנתבעת

פסק - דין

התובעים מבקשים כי יינתן צו קבוע האוסר על הנתבעת לבנות מרפסת תלויה, בהתאם להיתר בניה שקיבלה מאת הועדה המקומית.

1. עסקין בבית שנמצא ברח' חיים 22, בקרית ביאליק, וידוע כחלקה 217 בגוש 10445. הבית נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין.

2. הבית מורכב משני מבנים ובו סה"כ 24 דירות. 12 דירות בכל מבנה. כל אחד מהמבנים מורכב מדירות קוטג' בקומת הקרקע ובקומה הראשונה של הבית, אליהן הוצמד שטח גינה. מעל דירות הקוטג', ובקומה השנייה של הבית, קיימות דירות רגילות.

3. בהתאם לסעיף 3 לתקנון המוסכם, נקבע כי כל אחת מהכניסות של הבית תחשב כמבנה נפרד לצורך סעיף 59 לחוק המקרקעין.

4. הצדדים כולם הינם בעלי דירות במבנה מס' 1 כאשר חלקות משנה 1-6 שייכות לכניסה א' במבנה 1, ואילו חלקות משנה 7-12 שייכות לכניסה ב' במבנה 1.

5. הנתבעת הינה בעלים של דירה בקומה השנייה של הבית (חלקת משנה 6) הנמצאת מעל לדירת הקוטג' של התובע מס' 2, מר ליטבין (בעלים של חלקת משנה 3). המרפסת אמורה להבנות עד לקו האווירי שמפריד בין גינת ליטבין (חלקת משנה 3) לגינת משפחת אלבז



(חלקת משנה 2) (עמ' 1 ו-2 לפרוט' ביקור במקום מיום 22.9.14) ומעל חלון דירתו של מר ליטבין. שתיהן דירות קוטג' שבקומת הקרקע ובקומה הראשונה של הבית.

6. מר פניני יוסף, אביה של הנתבעת, הגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בקשה לקבלת היתר לבנייתה של מרפסת תלויה.

7. יצוין כי אביה של הנתבעת הציג יפוי כוח נטריוני ומכוחו טען כי הינו מוסמך להופיע בשם בתו בהליך הנוכחי. גם הבקשה להיתר בניה הוגשה על ידי מר פניני.

8. חלק מהתובעים הגישו לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, את התנגדותם לבקשה לבניית המרפסת.

9. הועדה המקומית החליטה בתחילה לדחות את הבקשה כדלקמן (החלטה מיום 9.3.14 המשך של נספח "ד" לכתב התביעה):

"לקבל את התנגדות השכנים ולדחות את הבקשה שכן זו גורמת למטרד לא סביר לדיירים להם צמודה הגינה. התוספת תהווה פגיעה בחזות הארכיטקטונית של המבנה כולו..." (ההדגשות אינן במקור).

10. מאוחר יותר הוגשה בקשה לדיון חוזר בהחלטת הועדה. הועדה החליטה בסופו של יום **לאשר** את הבקשה להיתר, **מבלי שפורטו נימוקים שעל בסיסם** החליטה הועדה לשנות את החלטתה הקודמת (החלטת ישיבת הועדה מיום 6.7.14 – נספח ו' לכתב התביעה, החלטה שיצאה ביום 15.7.14).

11. התובעים ציינו בפני כי לא הגישו ערר לוועדת הערר המחוזית על החלטה זו, מאחר שלא היו מודעים לאפשרות לעשות כן.

12. נוכח החלטת הועדה המקומית, הגישו התובעים ביום 14.8.14 בקשה בפני למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, אשר ימנע מהנתבעת לבנות את המרפסת עד לפסק הדין שינתן בתובענה העיקרית.

13. ביום 14.8.14 נעתרתי לבקשה במעמד צד אחד. ביום 21.8.14 קיימתי דיון בבקשה במעמד הצדדים. לאחר הדיון ביקשה הנתבעת, באמצעות אביה, לקיים דיון נוסף בבקשה לסעד הזמני, טרם תינתן החלטה בבקשה, ואף ביקשה להגיש סיכומים בכתב ביחס לבקשה.

14. בנסיבות אלה ולבקשת הנתבעת, נקבע מועד דיון נוסף בבקשה לסעד זמני ליום 22.9.14, אשר במהלכו הסכימו הצדדים, כי אותו דיון ישמש גם כדיון בתיק העיקרי. עוד הסכימו הצדדים, כי באותו מועד ייערך ביקור בבית המשותף, וכי לאחריו יוגשו סיכומי הצדדים ויינתן פסק דין בתובענה העיקרית (עמ' 4 ש' 8-11):



"אנו מסכימים שיינתן פס"ד בתיק העיקרי יחד עם הבקשה לסעד זמני על סמך חומר הראיות וכתבי הטענות שהוגשו היום ובדיון הקודם ביום 21.8.14, וזאת לאחר שיערך ביקור בבית המשותף. נבקש להגיש סיכומים בכתב".

15. בנסיבות אלה, צו המניעה הזמני נותר בתוקפו עד למתן פסק הדין.

טענות הצדדים

16. **התובעים** טוענים, כי לנתבעת אין את הרוב הדרוש לצורך בניית המרפסת כנדרש בהתאם לסעיף 71ב לחוק המקרקעין. עוד נטען כי בניית המרפסת תגרום לתובעים לפגיעה מהותית בדירותיהם ולפגיעה בבית המשותף.

17. התובעים מכחישים את טענת הנתבעת כאילו הם הרחיבו את דירתם באופן דומה (לצורך סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין).

18. הנתבעת, באמצעות אביה, טענה כי יש ברשותה את הסכמת רוב בעלי הדירות הדרוש בהתאם לחוק, כי חלק מבעלי הדירות בבית הרחיבו אף הם את דירותיהם על ידי בניית פרגולות המשמשות בפועל כמפרסות, ולכן יש לראותם כמי שביצעו "הרחבה דומה". על כן, יש לראותם כמי שמסכימים קונסטרוקטיבית לבנייה המבוקשת על ידי הנתבעת.

19. עוד טענה הנתבעת, כי התובעים מעלים טעמים תכנוניים בלבד להתנגדותם, ומשאלה נדחו על ידי הועדה המקומית, אין מקום לחזור ולדון בהם, שכן המפקח אינו מוסמך לדון בטענות תכנוניות.

דיון והכרעה

20. לצורך הכרעה במחלוקת בפני נדרש אני להכריע שתי שאלות מרכזיות:

א. האם יש לנתבעת את הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירתה (בין אם מכוח הסכמה מפורשת ובין אם בשל "הרחבה דומה").

ככל שהתשובה חיובית יש לבחון –

ב. האם הבניה המבוקשת עולה כדי "פגיעה מהותית" בתובעים כמשמעות מונח זה בסעיף 71ג לחוק.

הרוב הדרוש

21. **כלל**, הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, ודאי שלצורך בניה על אותו חלק שהוצמד, מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 62 לחוק). **החריג** לכלל זה הינו כאשר עסקינן ב"הרחבת דירה" כמשמעותה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין שהוסף לחוק במסגרת תיקון 18 בשנת 1995.



22. סעיף 71ב לחוק המקרקעין, קובע רף הסכמה נמוך יותר לצורך "הרחבת דירה". בהתאם לסעיף זה די בהסכמה של 75% מבעלי הדירות אשר צמודים לדירותיהם 2/3 מהרכוש המשותף, כדי לאשר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף וכן הצמדתם לדירה מסוימת: **"לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה"**.

23. בית המשפט העליון בפרשת עטייה קבע, כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב כ"הרחבת דירה" נדרשת "סמיכות פיסית" בין הדירה לבין "ההרחבה". אין חולק כי תנאי זה מתקיים בענייננו.

24. הפסיקה קבעה, כי בנייתה של מרפסת תחשב אף היא כ"הרחבת דירה" לצורך סעיף 71ב לחוק המקרקעין (ר' למשל עש"א [חי'] 50945-05-12 יובל ברק נ' דבורה קרש, פסק דין מיום 19.5.2013 (פורסם בנבו):

"אילו המערערים היו מבקשים להוסיף לדירה מרפסת פתוחה (תלויה), כי אז לא הייתה מחלוקת, שבניית המרפסת הייתה מרחיבה את דירת המערערים."

25. מסקנה זו מתיישבת עם לשון החוק והן עם תכלית התיקון, כפי שפורטה בהרחבה בפסק דין של בית המשפט העליון בפרשת עטייה, שכן בנייתה של מרפסת עשויה אף היא להקל על צפיפות הדיור ומשיקה פיסית לדירת הנתבע (בעניין זה ראה גם פסק דינו של המפקח ש' הילזר בתיק 27/12 נורית מור נ' יורם זיו אור (פורסם בנבו) וכן פסקי הדין המוזכרים שם, ובהם פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים בע"א 1415/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם).

26. התוצאה מן האמור לעיל הינה, כי בענייננו חל סעיף 71ב לחוק, ועל כן די ברוב של 75% מבעלי הדירות, ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כדי לאשר ההרחבה המבוקשת. בעניין זה יצויין כי התובעים לא חלקו על תחולת סעיף 71ב לחוק.

האם לנתבעת יש את הרוב הדרוש

27. כפי שיפורט להלן, לנתבעת אין הסכמה מפורשת של רוב בעלי הדירות כפי שנדרש בסעיף 71ב לחוק.

28. אציין כי לצורך ויתור על זכות קניינית ובמילים אחרות הסכמה של בעל דירה לבנייה המבוקשת על ידי בעל דירה אחר, נדרשת, ככלל, חתימה מפורשת על תוכנית הבניה עצמה (הגרמושקה) ולא די בטופס החתימות.



29. עם זאת במקרה שבפני, אפילו הייתי מניח, לטובת הנתבעת, כי די בטופס החתימות שהוצג, אין בידיה את הרוב הדרוש.

30. הנתבעת באמצעות אביה, הגישה בפני טופס הסכמת שכנים שהוגש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ושעליו חתמו הבעלים של חלקות משנה 1, 5, 7, 11, ו-12 (נ/2 ונ/3, סה"כ 5 בעלי דירות) כולם ממבנה מס' 1.

31. במהלך הדיון מיום 21.8.14 הוגשה הסכמה נוספת של משפחת חסין (עופר ורויטל חסין התובע מס' 7) לפיה למשפחת חסין אין שום התנגדות לבניית המרפסת (נ/1 – חוכרים של חלקת משנה 10).

32. **סיכום ביניים:** יחד עם הנתבעת עצמה (חלקת משנה 6) סה"כ יש בידי הנתבעת הסכמות של 7 בעלי דירות מתוך 12 במבנה מס' 1, שהם פחות מ-60% מרוב בעלי הדירות (כ-58%).

33. כאמור לעיל, הבית מורכב משני מבנים ובו סה"כ 24 יחידות דיור. אפילו הייתי מניח לטובת הנתבעת, כי די בקבלת הסכמה של רוב בעלי הדירות במבנה מס' 1 בלבד (שבו 12 יחידות) אין ברשותה את הרוב הדרוש.

34. כמו כן, אילו הייתי בוחן את הרוב הקיים בכניסה א' בלבד, ובה דירת הנתבעת (סה"כ 6 דירות, חלקות משנה 1 – 6, לאור הוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם לפיה כל כניסה תחשב כמבנה נפרד) הרי שלנתבעת יש הסכמה רק של 50% מבעלי הדירות.

35. זאת ועוד, אין חולק כי התובעים שנתרו בהליך (למעט הגב' זיו) לא חתמו על הבקשה להיתר. מכאן שחמשה בעלי דירות לא חתמו על הבקשה להיתר ומתנגדים לבנייה המבוקשת ואלה הם:

התובע מס' 1, אלבו – החוכר של חלקת משנה 2; התובע מס' 2, ליטבין – החוכר של חלקת משנה 3; התובע מס' 3 – קוזננצוב – החוכר של חלקת משנה 4; התובע מס' 5 – אוחיון רמי – החוכר של חלקת משנה 8 (מאחר ששם המשפחה זהה אציין כי "אוחיון אליס" החוכר של חלקת משנה 11 הסכים לבניה; התובע מס' 6 – גולדשטיין – החוכר של חלקת משנה 9.

36. אעיר כי הגב' חנה זיו הודיעה בדיון מיום 21.8.14, כי היא מבקשת לחזור בה מההסכמה שניתנה, אלא שהגב' זיו לא התייצבה לדיון שנקבע בתיק ליום 22.9.14. בנסיבות אלה, לא הוכח כי גב' זיו רשאית לחזור בה מהסכמה שניתנה. עם זאת, וכפי שפירטתי לעיל, גם יחד עם הסכמה לכאורה של הגב' זיו, אין ברשות הנתבעת את הרוב הדרוש.



37. **התוצאה** – לנתבעת אין הסכמה מפורשת של 75% מבעלי הדירות בבית בהתאם לסעיף 71ב לחוק.

38. יצויין, כי אביה של הנתבעת אישר בעצמו, כי יש ברשותם הסכמה מפורשת של 60% מבעלי הדירות בלבד (ר' עמ' 2 ש' 38 – 39 לפרוט' מיום 21.8.14).

הרחבה דומה

39. הנתבעת אישרה אם כן, כי אין בידה את הרוב הדרוש לבניית המרפסת, אך טענה כי יש לראות בחלק מהתובעים כמי שביצעו "הרחבה דומה". הנתבעת טענה, כי יש לראות את התובעים מס' 2, 3, 4 ו-7 כמי שמסכימים לבניה שבוצעה, שכן הם ביצעו "הרחבה דומה" נוכח בניית פרגולה שלטענת הנתבעת עולה כדי **מרפסת**.

40. סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, קובע כי בעל דירה שדירתו הורחבה, ייראו אותו כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין (ע"א 7156/96 **שואעי נ' בכרך**, פ"ד נג(1), 469) וכלשון הסעיף:

"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין".

41. בהתאם לסעיף קבעה הפסיקה, כי מאחר שעסקינן **"בהרחבה דומה"** הרי שלא נדרש כי תהא זהות בין ההרחבה שביצע השכן לבין הבניה המבוקשת כיום.

42. עם זאת, הפסיקה התוותה מספר פרמטרים שיש בהם כדי לסייע בפרשנות וביישום הגדרה זו. כך למשל קבע בית המשפט המחוזי בחיפה בעש"א (חי' 22123-10-10 **דוד חדד נ' דפנה זינגר** (פורסם בנבו – להלן: **"פרשת זינגר"**) כי:

"בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבנין, אין מקום להכשירה".

ברוח זו, נקבע בע"א 3235/02, **אביב דוד ואח' נ' גדולטר בכבוד רונית** (פרסום נבו), 02/03/03, כדלקמן:

"מקובלת עלינו הפרשנות לפיה 'הרחבה דומה' כמשמעה בסע' 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הינה הרחבה מסוג דומה - כך בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בנין אף אם אין שטחן של המפרסות זהה



**בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגזלת דירת
שכנו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה
נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף
אינה שונה באופן מהותי" (ההדגשות אינן במקור).**

מן הכלל אל הפרט

43. יישום הלכות אלה על נסיבות המקרה מוביל למסקנה ולפיה במכלול השיקולים והראיות שהוצגו בפני ולאחר שהתרשמתי מהבית באופן בלתי אמצעי במהלך הביקור במקום שערכתי ביום 22.9.14, עולה באופן ברור וחד משמעי כי **אין מדובר בהרחבה דומה**.

44. בתמצית אציין כי לא ניתן לראות בהצבתה של פרגולה על חלקת קרקע הצמודה לדירת התובעים, כ"הרחבה דומה" לצורך בנייתה של מרפסת תלויה. הנתבעת אמנם טענה כי, בפן התכנוני ובפן המיסויי (לצורך חיוב בארנונה) אין מדובר בפרגולה אלא מרפסת מקורה, אך אין בכך כדי להשליך על הדיון בפני הנוגע לפן הקנייני, כפי שהנתבעת עצמה טענה.

45. על אף ההגדרות והתנאים התכנוניים הנדרשים לצורך "קירוי" שיחשב כ"פרגולה", הנתבעת לא הוכיחה כי לצורך חוק המקרקעין, יש לראות בתובעים כמי שבנו מרפסת העולה כדי הרחבה דומה למרפסת התלויה אותה מבקשת הנתבעת לבנות.

46. כדי לבסס את טענתה, הפנתה הנתבעת להגדרתה של מצללה / "פרגולה" בחוק התכנון והבניה (תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003 שם נקבע, כי:
**"מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה
מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין
החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים
40% לפחות ממנו".**

47. הנתבעת טענה, כי בנסיבות המקרה ונוכח דרישת ה-40% הנ"ל ומאחר שמעל הפרגולה מונח משטח פלסטיק – אין מדובר בפרגולה.

48. הנתבעת גם ביקשה להפנות לפסה"ד שניתן בעמ"נ 27493-08-11 **שושנה מאנע ואח' נ' מנהל הארנונה**. פס"ד הדין מתייחס להגדרתה של פרגולה או מרפסת לצורך חיוב בארנונה.

49. אינני נדרש להכריע בעניין שכן השאלה בפני איינה האם הפרגולה שנבנתה עונה על ההגדרה בחוק התכנון והבניה (והאם היא עולה כדי "עבודה מצומצמת" וממילא אינני מוסמך לדון בעניין). המחלוקת בפני הינה קניינית, בשאלה אם מדובר ב"הרחבה דומה".



בעניין זה יש לבחון את מהות וטיב הבנייה שנעשתה בהתאם לחוק המקרקעין. השאלה האם הפרגולה שנבנתה מחייבת היתר אם לאו, אינה במסגרת סמכותי העניינית וממילא אין בה כדי להשפיע על התוצאה אליה הגעתי.

50. זאת ועוד, לדירות הקוטג' של התובעים, הוצמד שטח קרקע (בהתאם לתקנון המוסכם) ומכאן שהפרגולה הוצבה מעל שטח קרקע הצמוד לדירתם.

51. בתקנון המוסכם אמנם נקבע, כי: **"ידוע לבעלי הדירות שאליהם הוצמדו שטחי קרקע (חצרות) שאין זכויות בניה באותם שטחים"** (סעיף 2.ב. לתקנון המוסכם) ולכך ניתן אף להוסיף את ההלכה המורה, כי הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, אינה מקנה זכות לבנות על השטח שהוצמד (למשל: ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נד(3), 389) אך **אין באלה כדי לטשטש את השוני המהותי שבין הפרגולות שהציבו התובעים (או חלקם) לבין המרפסת אותה מבקשת הנתבעת לבנות, במיוחד נוכח התרשמותי מהבית בעת הביקור במקום.**

52. יודגש, כי לא ניתן להשוות בשאלת היקף וטיב השימוש ברכוש המשותף, בין בעל דירה שלדירתו צמוד שטח גינה המתוחם בגדר מבטון, ואותו בעל דירה מתקין פרגולה מעל שטח ההגינה, לבין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך בניית מרפסת תלויה בקומה השנייה של הבית מעל דירות הקוטג', וזאת בזיקה לסעיף 71ב(ג) (ר' למשל תמונה 7/).

53. אציין כי באשר לתובעת מס' 4 ולתובע מס' 7, ממילא הנחתי כי אלה מסכימים לבנייה המבוקשת. אין בכך כדי לסייע לנתבעת, שכן יחד עם שני אלה, יש ברשות הנתבעת סה"כ הסכמה של 7 בעלי דירות בלבד, כמפורט לעיל.

54. מכאן שנדרשתי לבחון האם התובעים מס' 2, 3 ו-5 ביצעו הרחבה דומה. (אין חולק כי תובע מס' 1 (חלקת משנה 2) לא ביצע הרחבה דומה (ר' פרוטוקול ביקור במקום מיום 22.9.14 לאור הפרגולה שבנו חלק מהתובעים, כאמור לעיל, לא ניתן לראות בכך משום הרחבה דומה).

55. בפרשת זינגר נפסק עוד, כי שטח ההרחבה, מהווה רק אחד הפרמטרים לצורך בחינת השאלה אם מדובר בהרחבה דומה. בענייננו לא הוצגו נתונים ביחס לשטחי הפרגולה של התובעים, וממילא זהו רק אחד המרכיבים. הנתבעת הציגה מסמך שנחזה להיות גרמושקה (נ/5) אך חסרים בו פרטים מהותיים. לא צויינו שטחי הבניה המבוקשים, אין חתימות של עורך התוכנית על המסמך, וכן חסרים פרטים מהותיים בדבר מיקום וצורת הפרגולה. אפילו אניח לטובת הנתבעת כי שטח המרפסת הינו 12 מ"ר (נ/11 - כפי שטען מר פניני) אין בכך כדי לשנות את התוצאה אליה הגעתי.



56. **סיכום ביניים**: לצורך הדיון בפני ודאי שהצבת פרגולה על שטח קרקע הצמוד לדירת התובעים, אינה יכולה להיחשב כ"הרחבה" דומה לצורך בניית מרפסת תלויה, שתשען על קונסטרוקציה מברזל, ואשר תחייב בנוסף **הרחבת פתח החלון** בדירת הנתבעת לכדי דלת יציאה למרפסת.

57. מקום בו מבקש בעל דירה לבצע הרחבה על הרכוש המשותף, עליו הנטל להוכיח כי יש בידו את ההסכמה הנדרשת לכך בחוק. ויודגש, על מבקש ההרחבה להוכיח הסכמה פוזיטיבית לבניה המבוקשת, והוא לא יוכל לטעון להסכמה בהיעדר התנגדות של בעל דירה אחרת. בהעדר הסכמה, כאמור, על הטוען לקיומה של הרחבה דומה להוכיח זאת. הנתבעת לא עמדה בנטל ואף הוכח כי אין מדובר בהרחבה דומה.

58. די באמור עד כה כדי לקבל את התביעה. למעלה מן הדרוש, אציין כי אפילו הייתה בידי הנתבעת הסכמת רוב בעלי הדירות בהתאם לסעיף 71ב לחוק, לא היה מקום לאפשר הבניה המבוקשת, נוכח "פגיעה מהותית" בחלק מבעלי הדירות כפי שאפרט להלן.

59. כפי שנקבע ב"פרשת זינגר" היקף השימוש ברכוש המשותף שונה בתכלית בין הצבת פרגולה על שטח קרקע מגודר וצמוד לדירה פלונית שהגישה לאותו שטח קרקע הינה מתוך הדירה בלבד, לבין בנייתה של מרפסת תלויה בחזית הבית ובקומה השנייה.

פגיעה מהותית

60. התובעים טוענים בנוסף, כי הבנייה המבוקשת תפגע בהם באופן מהותי וממשי.

61. סעיף 71ג לחוק המקרקעין קובע בעניין זה כי:

"בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי, רשאי לפנות למפקח בתביעה".

62. המלומד א' איזנשטיין מגדיר "פגיעה מהותית" כ:

"פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עימו גם תמורת פיצוי כספי הולם, כגון הסתרת אור, אוויר, נוף מטרד מתמשך וכו'".

(אריה איזנשטיין, **"יסודות והלכות בדיני מקרקעין"** (חלק שלישי – בתים משותפים) 218 (2001), כן ר' עו"ד עוז כהן **"בתים משותפים"** (מהדורה שנייה) 189 (2009) והדוגמאות שם). ובעניין זה ר' גס עש"א (חיפה) 35338-10-11, **מיכאל וייסבוך נ' רחל מלכה שמיר** (פרסום נבו), 15/04/12 (להלן: **"פסק דין וייסבוך"**).



מן הכלל אל הפרט

63. הוכח בפני כי בניית המרפסת עולה כדי פגיעה מהותית בתובעים :

א. המרפסת מתוכננת להבנות כשהיא כמעט נושקת לחלון דירת מר ליטבין. לאחר בניית המרפסת, המרחק בין החלק התחתון של המרפסת לחלון דירת מר ליטבין יהא כ-20 - 60 ס"מ. כך שזו תוצב ישירות מעל חלון דירת הנתבעים ותגרום להצללה של דירה זו (ר' ת/3, וכן עמ' 2 ש' 7 – 14 לפרוט' מיום 22.9.14 ונספח "ד" לתביעה).

ב. בניית המרפסת התלויה מחייבת ביצוע קיבועים לקיר הבית המשותף, דבר שיפגע בקיר הבית ובחזותו. כפי שהעיד מר גולדשטיין: "כל הקונסטרוקציה זה ממתכת. כך שיש לנו לחות גבוה, זאת אומרת שהחומר עם הזמן יקבל קורוזיה, ובאיזה יום יפול. צריך לקדוח את החורים בקיר המשותף וזה יפגע בקיר" (עמ' 2 ש' 17 – 19 לפרוט' מיום 22.9.14). אין חולק כי לא קיימת כוונה לצקת יסודות לבניית המרפסת.

ג. בניית המרפסת מחייבת הרחבת חלון דירתה של הנתבעת לצורך יציאה למרפסת שתבנה.

ד. בניית המרפסת תפגע בחזית הבית – כפי שגם קבעה הועדה המקומית בהחלטתה הראשונה: "התוספת תהווה פגיעה בחזות הארכיטקטונית של המבנה כולו". אכן כטענת הנתבעת, יש להפריד בין הדיון התכנוני לבין הדיון הקנייני, אך במקרה זה הנימוקים שפירטה הועדה המקומית בהחלטתה הראשונה אך מחזקים את המסקנה אליה הגעתי (גם ללא החלטת הועדה) ולפיה מדובר בפגיעה מהותית.

ה. המרפסת תפגע ותסתיר את האור לחדר המדרגות המשותף - המרפסת מתוכננת להבנות סמוך לחדר המדרגות המשותף שבו מותקנים כיום חלונות. בשל כך תראה המרפסת מתוך חדר המדרגות, דבר שיפגע אף הוא ברכוש המשותף.

64. יש לדחות מכל וכל את טענת הנתבעת כאילו התובעים פעלו שלא בחוסר תום לב. עדויות התובעים בפני בדיון מיום 22.9.14 היו מהמנות סדורות והצביעו על פגיעה ממשית ומהותית בזכויותיהם. הדברים קיבלו משנה תוקף נוכח הביקור במקום.

65. זאת ועוד, הנתבעים הודיעו כי אף הציעו לנתבעת לבנות את המרפסת במקומות אחרים של דירתה, כך שפגיעתה בתובעים תהא פחותה, אך הנתבעת סירבה.

66. טענת הנתבעת, כי גם התובעים הציבו מנוע של המזגן על הקיר המשותף אינה רלבנטית לעניין. בנוסף, ככלל הצבת מנוע מזגן על קיר משותף, הינה שימוש סביר (ר' ע"א 991/97 נציגות הבית נ' לילי אבן (פורסם בנבו). בנסיבות המקרה לא הוכח אחרת.



התוצאה

67. לאור כל האמור, אני מקבל את התביעה. ניתן בזאת צו קבוע האוסר על הנתבעת ו/או על אביה מר פניני יוסף ו/או מי מטעמם מלבצע עבודות בניה כלשהן מכל סוג שהוא, בהתאם להיתר בניה שקיבלו (היתר מס' 20140341) לבניית המרפסת בהתאם להחלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

68. הנתבעת תשלם לכל אחד מהתובעים 1, 3, 5 ו-6 את הוצאות ההליך **בסך 1,200 ₪** לכל אחד (סה"כ **4,800 ₪**).

69. לתובע מס' 2, מר ליטבין, תשלם הוצאות **בסך 1,700 ₪**.

70. לא מצאתי לחייב את הנתבעת לשלם הוצאות לתובעת מס' 4, מאחר שלא התייצבה לדיון שהיה קבוע ליום 22.9.14.

71. כל הסכומים הנ"ל ישולמו לכל אחד מהתובעים תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

72. יובהר, אני מורה על מחיקת התובע מס' 7, עופר חסין, כתובע בתיק זאת לאור הודעתו מיום 17.8.14 לפיה הוא מסכים לבניה המבוקשת (נ/1) ומשלא התייצב לדיונים בתיק.

73. באשר לבקשת התובעים כי אורה לועדה המקומית שלא להוציא היתר בניה לנתבעת, אינני מוסמך ליתן את הסעד המבוקש, מה גם שהנתבעת טענה כי כבר נתקבל היתר בניה.

ניתן בלשכתי היום, ד' כסלו תשע"ה, 26 נובמבר, 2014 בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין